司法公正与同理心正义*

杜宴林

摘　要：随着社会诉求的日趋多元化，司法的公正运作遇到较为复杂的困难局面。同理心正义既能最大限度实现个案的正义裁决，又能正确对待普遍性的正义寻求，显现出一种亲社会性的公共理性，可成为这一难题的破解之道。同理心正义既是多元动态的正义，又较好地诠释了正义的对等性和互换性，也展现出了主体间性的互动特质和共鸣效果，还一定程度上荷载了较为丰富的正义德性。同理心正义尽管发端于心灵或情感体验，但完全能够经受住法律科学性的检验。同时，它也并非至善的正义，其操作机制存在一定的缺陷，也会诱发一些不利因素的产生。

关键词：个案正义　司法公正　同理心正义　公共理性

作者杜宴林，吉林大学理论法学研究中心/司法文明协同创新中心教授（长春 130012）。

一、问题的提出

当代中国司法理论界和实务界正呈现出一种新的景象：理论上的司法人文关怀以及实践中的司法改革，共同推进和培育中国特色社会主义司法文明。肇始于1996年并在实践中不断完善的被害人参与刑事诉讼制度无疑是其重要标志。该制度的确立，有效地化解了新中国成立以来渐次形成的超职权主义诉讼模式的弊端，保障了被害人参与诉讼活动的程序权利及其作用，符合“参与即正义”的程序正义精髓。①然而，这也意味着现代法治意义上的公正审判将面临着重大挑战。

* 本文为国家司法文明协同创新中心、国家社科基金项目“乡土社会的变迁与基层司法创新机制研究”（批准号12BFX015）以及教育部人文社科重点研究基地重大项目“以人为本的法治观研究”（批准号2009JJD820003）共同资助的研究成果。

① 参见 R. S. Summers, “Evaluating and Improving Legal Processes—A Plea for ‘Process Values’,” *Cornell Law Review*, vol. 60, no. 1, 1974, pp. 25-26.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一方面，从法院层面上看，被害人参与诉讼，有力地加强了被害人追究犯罪的权利而为学界津津乐道；① 但不可否认的是，由于中国自古以来的“受害人本位”传统以及相应的民愤和情感说服技术，② 它也导致了被害人中心地位的进一步确立和巩固。被害人诉求的多元化也很可能使得裁决流于“盲人摸象”式的试错性决断：裁决往往因回应和安置当事人的利益诉求充满交涉性、任意性，法院很难稳定地输出正义。正如德国法学家赫费所言，正义的一个起码条件就是禁止任意性。③ 尽管有学者甚至为此提出了定罪和量刑分立的变革性设想，但由于被害人具有独立的诉求和利益，④ 这一设想目前看仍然难以获得共识。

另一方面，从被害人层面上看，被害人参与诉讼，很可能加剧问题的复杂化程度：被害人主观体验和生活经验的不同，使得参与诉讼的动力、能力，特别是利益诉求、权利主张均千差万别，其结果是“参与”有了良性/恶性的双重可能性。⑤ 良性尚可期，恶性则危害极大，因为在这种情况下，当事人之间完全有可能合谋串通、非法牟利，损害社会的公平正义，司法公正自然也难以真正实现。

二、问题的破解与同理心正义的引入

这表明，既要最大限度满足各方的诉求，实现司法为民，又要做到司法公正、社会认可，显然需要最大限度整合各种诉求的正当性/合法性的机制和理据，以达成公认的判决依据，否则很容易形成众口难调、进退失据乃至价值虚无的局面，造成社会秩序混乱。因此，那种试图从具体法律条文中寻求回答具体法律问题的方法已失效，应转而寻求一种正义的首要原则，一种政治—道德的规范，使之可能作为公共理性意义上法律责任的基础。因为在这里很可能存在复数的正确主张，应进行有效取舍、整合，寻求各种诉求的最大公约数，形成各方均能最大限度接受的裁决理由。事实上，因为有取舍，这种裁决理由只能是图尔敏意义上的满意或较优的理由，⑥ 裁决也就没有绝对正确性、客观性和确定性。

---

① 陈光中：《加强司法人权保障的新篇章》，《政法论坛》1996 年第 4 期。

② 参见季卫东：《中国司法的思维方式及其文化特征》，葛洪义主编：《法律方法与法律思维》第 3 辑，北京：中国政法大学出版社，2005 年，第 67—88 页。

③ 赫费：《政治的正义性——法和国家的批判哲学之基础》，庞学铨、李张林译，上海：上海译文出版社，1998 年，第 29 页。

④ 陈瑞华：《论量刑程序的独立性——一种以量刑控制为中心的程序理论》，《中国法学》2009 年第 1 期。

⑤ 季卫东：《法治中国的可能性——兼论对中国文化传统的解读和反思》，《战略与管理》2001 年第 5 期。

⑥ Stephen E. Toulmin, *An Examination of the Place of Reason in Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1953, pp. 82-85.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

既往的司法经验告诉我们，这一正当性/合法性机制必须根植于中国独特的国情基础上，置国情不顾而简单地照抄照搬无异于缘木求鱼。中国司法国情的独特性在于：不同于具有深厚自由主义法治传统的西方社会，也不同于小型且文化传统较为单一的现代族群社会，当代中国社会是以社会主义为本质属性和发展方向，在充分认识、吸收人类文明发展的一切优秀成果，把握事物发展规律的基础上，挖掘出符合我国国情的发展道路的社会。这是由中国的社会性质和根本制度所决定的。因此，司法既要虚心学习、借鉴人类社会创造的一切文明成果，也不能数典忘祖，照抄照搬别国的经验和模式。它必须立足于中国的法律文化传统、现实国情之上，辩证取舍，择善而从。对此，法律人类学给予了最警醒的论证：法律本质上只是一种地方性知识。①

1. 道德/情感仍然是中国社会秩序原理的重要诉求。在传统中国，对此的最好注脚之一无疑是西周以来“明德慎罚”、“出礼入刑”、“德主刑辅”法制模式和传统的确立和延续。这样的模式中，法律缺乏独立性、自治性，法律和道德合而为一，其中德是首要的价值取向，而所谓的法律，实际只是赏善惩恶的代名词。② 其基本的秩序原理，正如黄宗智先生所指出的，无疑是以伦理道德价值而不是普适的演绎逻辑所主导的，③ 在立法上，以礼入法，法律即是道德；在法律适用上，恭行天理，执法原情，情、理、法兼顾，并特别注重公道、同情、忍让、妥协、仁爱等伦理价值的整体考量及动态调适。④ 这客观上有利于造就国人容易接受的兼容共存、相互依赖的“关系本位”秩序，⑤ 但也因深陷泛道德化泥淖⑥而使其注定与现代法律秩序无缘。对此，黑格尔和昂格尔的认识无疑具有很强的代表性。⑦ 而在当代中国，理论界和实务界均承认，法治中国的建设仍然有大量的法律道德主义的理论和事实空间，就理论空间而言，受制于强韧的德治传统和社会心理影响，当代中国其实很难接受没有道德内容的法治观。与此同时，道德是现代法律合法性证成的基本路径，

① 克利福德·吉尔兹：《地方性知识：事实与法律的比较透视》，梁治平编：《法律的文化解释》，北京：三联书店，1994 年，第 126 页 。

② 参见张晋藩：《中国法律的传统与近代转型》，北京：法律出版社，2009 年，第 38—40 页；梁治平编：《法律的文化解释》，第 338 页。

③ 马克斯·韦伯：《经济与社会》下卷，林荣远译，北京：商务印书馆，1998 年，第 138—142 页。

④ 参见张晋藩：《中国法律的传统与近代转型》，第 3—26、99—113 页；梁治平：《寻求自然秩序中的和谐》，北京：中国政法大学出版社，1997 年，第 300—301 页。

⑤ 梁漱溟：《中国文化要义》，上海：上海人民出版社，2011 年，第 78 页。

⑥ 参见梁治平编：《法律的文化解释》，第 310—344 页。

⑦ 参见黑格尔：《哲学史讲演录》第 1 卷，贺麟等译，北京：商务印书馆，1981 年，第 119 页；昂格尔：《现代社会中的法律》，吴玉章、周汉华译，北京：中国政法大学出版社，1994 年，第 92 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

它既关联着法律内容的正当，又关联着法律良善的评判，这一点，中西方法律概不例外。① 事实上，作为社会控制的不可或缺的基本方式，两者在维护社会秩序方面一直相辅相成。这均表明，法律与道德依然密不可分且直接相关，② 所要警惕的只不过是泛道德化现象的死灰复燃，尽管这绝非易事。

2. 司法缺乏一以贯之的自治性逻辑。正因法、德不分，德居核心地位，使得司法往往诉诸道德情理，最终实现以“情理”为基础，“情、理、法”三法源的融通为一的正义裁决。由于情理本质上说是“深藏于个人心中的感觉而不具有实定性，但它却引导听讼者的判断；而且听讼以平息争讼为目的，当事人对事实不再争执时即告终结”。③ 由此，司法问题最终极有可能演化为一种盲人摸象式的寻找各方利益最佳均衡点的博弈游戏。④ 当然，这种司法模式有其优点，那就是司法的相对人性化；但其缺点同样不容忽视：由于缺乏按规则来判断、伸张权利的意识，这种司法“圆通”有余，确定性、普遍性不足，极端情形下甚至可能蜕化为一种司法擅断。也正基于此，韦伯断言其为“卡迪司法”。⑤

3. 社会公平正义的诉求仍然占据突出的位置。一方面，这是我国社会主义制度的必然要求。“社会主义最大的优越性就是共同富裕”，⑥ 也即更大程度的社会公平正义，英国著名的马克思主义分析学派代表人物希普诺维奇如此断言：“正是社会主义对于实证性正义和平等的承诺，才产生出一个善待并需要受法治之保护的消极自由的社会”。⑦ 另一方面，这种社会公平正义的吁求也是当下中国社会时代精神状况的真实折射和价值期待。社会两极分化导致了“社会结构紧张”和社会公众“公正失衡”，由此社会公平正义理应成为当下时代公义和社会发展之道。⑧

上述独特国情决定了当代中国正当性司法裁决“既不是简单的强制性判定，也

---

① 参见 Mark Tebbit，*Philosophy of Law*：*An Introduction*，2nd ed.，London：Routledge，2005，p. 3.

② 黄宗智：《道德与法律：中国的过去与现在》，《开放时代》2015 年第 1 期。

③ 参见林端：《韦伯论中国传统法律》，北京：中国政法大学出版社，2014 年，第 69 页。

④ 季卫东：《法治中国的可能性——兼论对中国文化传统的解读和反思》，《战略与管理》2001 年第 5 期。

⑤ 韦伯：《中国的宗教：宗教与世界》，康乐、简惠美译，桂林：广西师范大学出版社，2004 年，第 157 页。

⑥ 《邓小平文选》第 3 卷，北京：人民出版社，1993 年，第 364 页。

⑦ 希普诺维奇：《社会主义法律之概念》，转引自童世骏：《社会主义今天意味着什么：近期西方左翼人士的社会主义观》，华东师范大学当代中国马克思主义研究中心：《社会主义发展的历史进程研究》，上海：上海人民出版社，2001 年，第 353 页。

⑧ 参见刘欣：《当前中国社会阶层分化的多元动力基础——一种权力衍生论的解释》，《中国社会科学》2005 年第 4 期；王绍光：《大转型：1980 年代以来中国的双向运动》，《中

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不是纯粹根据逻辑从法律推导出的具体结论”，如同共享儒家法文化的日本一样，①而应是兼及事实与规范、实然与应然、个别与一般的考量，以利益“估价”作为阿基米德支点，调和、恰当地限制和尊重所包含的各种利益，博弈均衡，情法兼顾。这也就是说，仍然需要“情、理、法”兼顾的实质理性主义精神。② 其最终目标仍然是现代法治关照的理性生活秩序即法律规则治理下的目的性事业。③ 由此，其正义的基本形象呈现出超越机械司法/形式理性，而迈向现代性反思后的社会学司法/实践理性的正义，毕竟“法律正在进入一个社会学的时代”。④

基于上述正义的首要原则和实践理性的吁求，本文认为，有必要引入“同理心正义”理论：一方面，当下中国亟需建构的司法正义原则完全可以理解为“每个人获得其应得的东西”⑤且“没有根本分歧的合法化思想”。⑥ 鉴于利益诉求多元化的现实，这至少意味着各方利益间的“权衡挑战”，如同新法律道德主义头面人物皮特森所发现的那样。⑦ 这是一项充满了巨大困难的使命，而且迄今尚未发现一项杰出计划在实现这一目标时能够声称自己体现了“绝对的正义”。⑧ 这也就是说，法官在努力寻求一种成熟的、具体的正义裁决时，不得不更深刻、更敏锐地洞察各方诉求的奥秘和复杂性，考虑大量的变量和偶然情形。认知心理学研究告诉人们，这些问题的解决完全可以依靠换位思考、将心比心的同理心的细腻认知作用和辩证思维来实现。也正是在此意义上，索罗教授一再主张：“司法公正的品质必然要求法官对诉讼中各方当事人给予中立、不偏不倚的同情或移情，以很好理解、体认在他面前的各方当事人的利益和情感诉求”，“司法公正某种程度上就是由正确的移情、适度、中立地关爱各方当事人的利益构造的”。⑨

正义乃是一种关注人与人之间关系的美德。“正义本身乃是‘他者之善’或‘他

国社会科学》2008年第1期。

① 棚濑孝雄：《纠纷的解决与审判制度》，王亚新译，北京：中国政法大学出版社，2004年，第7页。

② 马克斯·韦伯：《经济与社会》下卷，第139页。

③ 富勒：《法律的道德性》，郑戈译，北京：商务印书馆，2005年，第124—125页。

④ 唐·布莱克：《社会学视野中的司法》，郭星华等译，北京：法律出版社，2002年，第2页。

⑤ 博登海默：《法理学、法律哲学与法律方法》，邓正来译，北京：中国政法大学出版社，1998年，第264页。

⑥ 赫费：《政治的正义性——法和国家的批判哲学之基础》，第68页。

⑦ Thomas Søbirk Petersen, “New Legal Moralism: Some Strengths and Challenges,” *Criminal Law and Philosophy*, vol. 4, no. 2, 2010, pp. 215-232.

⑧ 博登海默：《法理学、法律哲学与法律方法》，第297页。

⑨ Lawrence B. Solum, “Virtue Jurisprudence: A Virtue-Centered Theory of Judging,” *Metaphilosophy*, vol. 34, nos. 1/2, 2003, pp. 196-197。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者之利益'，因为它所为的恰是有益于他者的事情"。因而，为了有效地发挥作用，正义呼吁人们把他们从那些唯一只顾自己利益的冲动中解放出来。① 作为一种正义形式，司法公正概不例外，并在司法领域为人们指出了检验场域。当然，这也隐含了司法公正含义的边际性质，即富有意义的司法公正与非公正的基本界限就在于司法公正的公共理性：满足个人的合理需要和主张，并与此同时促进生产进步和提高社会内聚性的程度，这是维续文明的社会生活所必需的，也是一切正义包括司法公正的目标。②而同理心正义无疑深蕴着这样的公共理性精神。赫费指出，在讨论正义时，如果要排除个人的偏好、价值观和理念，那么换位思考、将心比心的同理心正义原则完全可以胜任，因为它"要求人们在对待别人时要充分考虑他们的需要、利益和理念，就像期望他们对待自己那样；这个公式至少表现了较好地接近为每个人带来利益的原则"；③ 也是在此意义上，霍布斯把它作为法律的基本原则来看待。④ 事实上，这也是新法律道德主义代表人物乔治所开出的面对"权衡挑战"时的"金规则"的药方：己所不欲勿施于人的同理心正义答案。⑤

总之，这种同理心正义理论，既能有效满足复杂诉求下个案的实质性公道，又能正确对待现代形式法治意义上的普遍性正义寻求，显现出一种更为切实可行的理性或正义模式。也基于此，我们也可以得出结论认为，它和实践唯物主义公正观的本质相通。⑥ 事实上，不管是东方文化还是西方文化，同理心正义都被当做一种思维方式和行为标准，⑦ 所不同的是它们或采取宗教形式或采取世俗形式。在中国，最为我们熟知的无疑是："己所不欲，勿施于人。"现实生活中人们也常说："人同此心，心同此理"。在西方，则见之于"你们愿意别人怎么待你们，你们也要怎么待人"教谕式告诫中。而引入同理心做法律哲学乃至正义哲学研究，国内外已大有人在并逾成共识之势。⑧ 而实践层面，学者的研究发现，作为同理心正义的法律实践

① 博登海默：《法理学、法律哲学与法律方法》，第 264—265 页。

② 博登海默：《法理学、法律哲学与法律方法》，第 252 页。

③ 赫费：《政治的正义性——法和国家的批判哲学之基础》，第 68 页。

④ 霍布斯：《利维坦》，黎思复、黎廷弼译，杨昌裕校，北京：商务印书馆，1985 年，第 14、26 章。

⑤ Robert P. George, "Does the 'Incommensurability Thesis' Imperil Common Sense Moral Judgements?" *American Journal of Jurisprudence*, vol. 37, no. 1, 1992, pp. 185-196.

⑥ 参见马俊峰：《马克思主义公正观的基本向度及方法论原则》，《中国社会科学》2010 年第 6 期。

⑦ 参见赵汀阳：《论可能生活》，北京：中国人民大学出版社，2010 年，第 295—317 页。

⑧ 参见许章润：《法律的实质理性——兼论法律从业者的职业伦理》，《中国社会科学》2003 年第 1 期；谢鸿飞：《中国民法典的生活世界、价值体系与立法表达》，《清华法学》2014 年第 6 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一直大行其道，必须认真对待。①

三、同理心正义的基本蕴涵及其司法实践

同理心通常在认知心理学中被译为移情、共情，“观点采择”，亦即把他人体验当前化、对陌生主体及其体验行为的经验，② 包括了情绪移情和认知移情、完全移情与不完全移情等基本分类。③ 现代认知心理学告诉我们，认识他人不是什么难题，难就难在站在对方的角度设身处地地客观理解他人，将心比心，甚至改变原本的做法甚或打消初衷。当然，这种改变或打消并不意味着同化，而是透露着体谅和尊重。其基本的逻辑支点是现代认知——行为科学的研究结论，移情是人类的本性，④ 能够良好指引人们更为全面认知和判断真实的个案事实的复杂性和丰富性，并慎思决策与行为。对此，宾默尔认为，移情就是指一个人“对别人的体验必须达到能站在他们的角度从他们的观点出发来看待问题的程度，否则他就不能预测他们的行为而无法做出最优反应”。⑤ 与此同时，移情往往与利他行为存在紧密联系，并升华出追求正义的动机，甚至对基于“需要”和“付出”的公正性原则产生实质性的作用。⑥ 只有移情才是可以实现的均衡，⑦ 公正的司法裁决也难以例外。当然显见于儒家文化的格物致知、正心诚意的“忠恕”之道——“尽己之谓忠，推己之谓恕”⑧ 无疑为此提供了耳熟能详的有力的论证。总之，移情这种能力，有利于洞识复杂信息，体现了人的“亲社会性”及相应的公共理性的属性，⑨ 深蕴着正义的契机。

作为一种人类特有的人际认知模型，移情有四个基本成分：情绪认知，客观认知和区分别人的情绪；观点采纳，代入他人处境，体验其经验；情绪体验，类似别

---

① 黄宗智：《中西法律如何融合？道德、权利与实用》，《中外法学》2010年第5期。

② 参见艾迪特·施泰因：《论移情问题》，张浩军译，上海：华东师范大学出版社，2014年，第21页。

③ 参见 N. Eisenberg and P. A. Miller, *The Relation of Empathy to Prosocial and Related Behaviors*, Psychological Bulletin, vol. 101, no. 1, 1987, pp. 91-119.

④ 万俊人：《真实的亚当·斯密》，罗卫东：《情感、秩序、美德——亚当·斯密的伦理学世界》，北京：中国人民大学出版社，2006年，第15页。

⑤ 肯·宾默尔：《博弈论与社会契约（第1卷：公平博弈）》，王小卫、钱勇译，韦森审订，上海：上海财经大学出版社，2003年，第39页。

⑥ 参见 Daniel Batson, “Empathy, Altruism, and Justice: Another Perspective on Partiality,” *in L. Montada and M. J. Lerner, eds.*, Current Societal Issues About Justice, *New York: Plenum Press*, 1996, *pp.* 49-66.

⑦ 肯·宾默尔：《博弈论与社会契约（第1卷：公平博弈）》，第76页。

⑧ 朱熹：《论语集注·里仁第四》，北京：中国社会科学出版社，2013年，第23页。

⑨ 玛莎·努斯鲍姆：《诗性正义：文学想象与公共生活》，第108—109页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人那样产生同样的情绪反应；反应决策，理智地对他人情况做出反应。① 同理心的内在意蕴，决定了同理心正义的如下司法实践运作机理。

第一，移情联想，查明事实。这是亚当·斯密和阿玛蒂亚·森笔下“公正的旁观者”的典型形象。它表明，同理心在整合多元诉求方面须有的放矢，相关作业者愿意且自觉地设身处地“投射”或“内在地参与”各方当事人体验和经验中，善意、全面地感知、把握和查明事实真相，以达至“感同身受”的同情、交融式理解，即互动基础上心智的共通，② 进而识别各方多元诉求竞争的实质。所谓自觉，即把他人体验当场化。正如黑格尔所言：“经验的原则包含一个无限重要的规定，就是为了要接受或承认某个内容为真，我们必须自身出现在那里。”③ 其次是“善意”，一种相通于伽达默尔意义上的“善意”，即承认尊重对方的经验体验或许是正确的，以及以“经验的开放性”作为基本前提。“真正的经验就是这样一种使人类认识到自身有限性的经验”，④ “没有相互间的开放就没有真正的人际联系”，⑤ 也就没有相应的客观性、全面性感知和理解。即不仅能够认清当事人意识到的意义，而且还能认清那些当事人尚未意识到的意义；⑥ 感受到在场者因其处境而产生的那种情感状态，尤其是想象、认识到不在场的当事人的利益。⑦

第二，位阶排序，维护社会生活的基本秩序。（1）这是同理心本身荷载的“亲社会性”价值取向：合作、互惠和利他，社会生活的正义秩序也就不言自喻。（2）多元诉求的无序竞争将不可避免带来社会失序的危机。⑧（3）这更是法的实践品格和价值的基本体现：赏善罚恶，定纷止争，冲突解决。正如庞德曾指出的，在法律调整和安排的背后“总有对各种互相冲突和重叠的利益进行评价的某种准则”。⑨（4）个人的关系存在而非单子式存在的社会事实也使得多元诉求的位阶排序有了现

① W. L. Marshall et al.,“Empathy in Sex Offenders,” *Clinical Psychology Review*, vol. 15, no. 2, 1995, pp. 99-113.

② 菲利普·佩迪特：《人同此心：论心理、社会与政治》，应奇等译，长春：吉林出版集团有限责任公司，2008 年，第 408 页。

③ 参见汉斯-格奥尔格·伽达默尔：《真理与方法：哲学诠释学的基本特征》上卷，洪汉鼎译，上海：上海译文出版社，1992 年，第 456 页。

④ 汉斯-格奥尔格·伽达默尔：《真理与方法：哲学诠释学的基本特征》上卷，第 459 页。

⑤ R. E. 帕尔默：《伽达默尔哲学的七个关键术语》，《安徽师范大学学报》2002 年第 5 期。

⑥ 《罗杰斯著作精粹》，刘毅、钟华译，北京：中国人民大学出版社，2006 年，第 120—121 页。

⑦ 波斯纳：《法律理论的前沿》，武欣、凌斌译，北京：中国政法大学出版社，2003 年，第 252—253 页。

⑧ 参见秦小建：《价值困境、核心价值与宪法价值共识》，《法律科学》2014 年第 5 期。

⑨ 罗斯科·庞德：《通过法律的社会控制》，沈宗灵、董世忠译，北京：商务印书馆，1984 年，第 50 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实的理据和可能性，同时也决定了诉求排序的基本原则须符合社会发展的基本规律。宾默尔尝试提供了生存博弈基础上的道德博弈进而达致公平的方案。① 霍夫曼则强调，应当与法律原则相勾连，特别是一些亲社会原则，比如公民宪法权利原则等等，使移情变得与法律相关且适度。②

第三，反思权衡，互相求证。它其实是一种沟通技巧，一种“自成一类的经验性行为”，并暗含了某种程度的类比、隐喻、象征、暗示等“讲道理”式的修辞手法。③ 可见，同理心在整合多元诉求方面的目标不是截然的非此即彼的思维方式，恰恰相反，它是在约束私己心，尊重、顺应多元诉求前提下进行权衡作业：旨在和而不同，互利共赢，完成自我正当性证明和合法性辩护。在此基础上，反复进行克制性、互动性对话和论证，将心比心，以寻找最大公约数。这里的最大公约数通常表现为某个日常生活经验范畴。日常生活经验的相似性决定了整合多元诉求、达成共识的可能性。这里的最大公约数还是一个动态的“暂时的结论”或者“未完成的协议”，随着开放性、反复性、克制性的互相求证而发生变化。这种寻找最大公约数的过程通常表现为晓之以理、动之以情、寻找均衡点的日常生活经验博弈的过程，其实质是一种消解极端对立的思维方式，趋于公共理性的中点或适中的均衡。概言之，各方退而求其次，亦此亦彼。

第四，理由优化，构筑和巩固共识。权衡诉求的同理心作业应始终注重理由优化的论证和法律论辩逻辑的论证，以最终形成好的行动理由。④ 所谓理由优化的论证，也即同理心整合多元诉求作业的过程是一个接受理由的竞争与反驳，以应对各方诘难，不断自我修正、形成更好的理由的过程，一个多元诉求的相互沟通、有序竞争、包容差异、审慎构筑共识的实践理性展开的过程。在中国，这种好的理由通常首先表现为某个基本规范或底线伦理，然后才是各方诉求的自由论证和相互理解，会通于前文宾默尔的生存博弈和道德博弈，最终由法官裁决终结，由此所形成的判决必然意蕴了个体尊重，同时又有克制自我、超越自身偏见、同舟共济的情怀。⑤

上述运作机理揭示了同理心是如何达至司法公正的，并预示了司法公正至少包含了如下内涵和特征：

第一，多元、动态正义。情境提供正义的论据，情境的不同，决定了移情的经

---

① 肯·宾默尔：《博弈论与社会契约（第 1 卷：公平博弈）》，第 55—56 页。

② Martin L. Hoffman，“Empathy，Justice，and the Law，” *in Amy Coplan and Peter Goldie*，*eds*.，Empathy：Philosophical and Psychological Perspectives，*New York*：*Oxford University Press*，2011，*pp*. 253-254.

③ 参见张浩军：《施泰因论移情的本质》，《世界哲学》2013 年第 2 期。

④ Stephen E. Toulmin，*An Examination of the Place of Reason in Ethics*，pp. 82-85.

⑤ 参见 Richard Rorty，*Philosophy as Cultural Politics Philosophical Papers*，vol. 4，Cambridge：Cambridge University Press，2007，pp. 42-55.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

验和体验自然也不同，司法公正内涵自然复杂多样，由此正义也就有了多元、动态的契机。至少在当下中国，它可能表现为经济正义，也可能表现为个体自主及“参与性平等”的政治价值，还可能表现为与个体自我认同、“好生活”等诉求相联系的一种文化—政治价值。①

第二，对等和互换的正义。一般而言，对等性和互换性是正义或公正的基本条件。② 同理心正义无疑是对等和互惠的较好诠释。合格的同理心运作须代入他人处境为前提，即“理解另一个体验的主体意味着在想象之中从他的立场当下化这个主体”。③ 顺理成章的是，同理心正义必然注重角色对等或地位互换，其根本指向是“试图发现当把地位差异考虑在内时能够产生什么样的公正关系”，④ 以担保其可接受性，并呈现出互换正义的色彩。

第三，主体间性的正义。角色对等或地位互换，带来人际间的相互理解和帮助，也使得同理心正义具有较好的双向交流过程，⑤ 也即其正义内容的获得、深化和校验，均来自于主体间移情式体验及其背后的主体间性的力量。同理心正义只是择优的反思均衡的证立性结论，绝非正义的终极形态或“意义的大陆”。⑥

第四，共鸣与常识的正义。同理心运作的共鸣属性主要根源于“想象性投射”、“模拟”机制及其经验性基础：日常生活经验的大体相似性。同理心在旁观者和当事人之间架起了跨越鸿沟的桥梁，并促使旁观者投射、模拟并采用他们的观点，关切和体谅他们，自然能产生情感共鸣和感同身受的积极回应。所谓“人同此心，心同此理”。由此也使得同理心正义有了这样的可能——与常识发生关联而具有丰富的日常蕴含，因而成为“常识正义”的代名词。⑦ 有中国学者认为，这种作为常识正义的同理心正义一直是中国法文化中正义的核心形式，⑧ 而耶尔·塔米尔则认为：“在什么东西构成了适当的接纳标准的问题上，最好的指南似乎是常识。”⑨

---

① 邓正来：《中国语境中的社会正义问题——序〈转型中国的社会正义问题〉》，《法制与社会发展》2013 年第 5 期。

② 参见赵汀阳：《论道德金规则的最佳可能方案》，《中国社会科学》2005 年第 3 期。

③ 耿宁：《孟子、斯密与胡塞尔论同情与良知》，《世界哲学》2011 年第 1 期。

④ 赵汀阳：《论道德金规则的最佳可能方案》，《中国社会科学》2005 年第 3 期。

⑤ 参见克利福德·吉尔茨：《地方性知识：阐释人类学论文集》，王海龙、张家宣译，北京：中央编译出版社，2000 年，第 203 页。

⑥ 参见克利福德·格尔茨：《文化的解释》，韩莉译，南京：译林出版社，1999 年，第 37 页。

⑦ 参见徐贲：《通往尊严的公共生活：全球正义和公民认同》，北京：新星出版社，2009 年，第 2 部分第 2 章“分配正义与群体认同”。

⑧ 参见张伟仁：《中国法文化的起源、发展和特点（下）》，《中外法学》2011 年第 1 期。

⑨ 耶尔·塔米尔：《自由主义的民族主义》，陶东风译，上海：上海译文出版社，2005 年，第 31 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第五，德性的正义。现代认知心理学认为，富有情感色彩的换位思考是带来纯粹利他（区别于血缘利他和工具性利他）行为的必要条件，① 它将促使人们思考如何共存并协调一致，由此同理心正义遵奉互利共赢、休戚与共的行为选择和行动逻辑。并因此而具有较好的道义性和相当的道德感召力：较大程度荷载了世道人心和道德直觉，甚至伯尔曼意义上的直觉和献身。②

同理心正义作为多元动态的正义，较好地诠释了正义的对等性和互换性，也展现出主体间性的互动特质和共鸣效果，荷载了一定程度的正义德性。因此，从内容属性上很难将它归类为某种具体的正义模式。尽管如此，从其发生机制而言，我们还是可以将其归结为作为情感的正义或曰正义感。有学者认为，这种“正义感”历史上一直是主导和支配中国社会生活的正义模式。③ 即使在权利诉求渐趋多元化的当代中国，④ 它仍然有其存续可能空间。因为这种正义感决定了什么是正当的。⑤ 事实上，同理心正义的裁决通常是基于经验的“非演绎性的、比较型的实践推理”，⑥ 一种寻找均衡点的反复博弈和尝试，某种意义上类似于英国普通法的运作逻辑。这个过程已经为芒罗·史密斯表述如下：“在以规则和原则的形式清晰表述社会正义感的努力中，发现法律的专家们所用的方法一直都是实验性的，判例法的规则和原则从来没有被当作终极真理，而只是作为可资用的假说……每个新案件都是一个实验。如果人们感到某个看上去可以适用的、已被接受的规则所产生的结果不公正，就会重新考虑这个规则。”⑦

四、同理心正义与现代法律的科学性宿命

尽管同理心正义具有一定的实用性，⑧ 但作为一种移情体验的正义，无论如何它都很难被人所看好，至少人们会对其将信将疑。罗素的经典表达加深了这样的担忧：

---

① 葛岩、秦裕林、何俊涛：《同感研究沿循“自下而上”和“自上而下”的双加工模式》，《中国社会科学报》2012 年 10 月 10 日，第 B02 版。

② 参见伯尔曼：《法律与宗教》，梁治平译，北京：中国政法大学出版社，2003 年，“导言”，第 1—2 页。

③ 参见许章润：《法律正义的中国语境——一种关于正义的程序主义法权进路（上）》，《战略与管理》2009 年第 5/6 期合编本。

④ 参见李建华：《道德情感论——当代中国道德建设的一种视角》，长沙：湖南人民出版社，2001 年，第 103 页。

⑤ 张乃根：《西方法哲学史纲》，北京：中国政法大学出版社，2002 年，第 3 页。

⑥ 玛莎·努斯鲍姆：《诗性正义：文学想象与公共生活》，第 114 页。

⑦ 本杰明·N。卡多佐：《司法中的类推》，《外国法译评》1998 年第 1 期。

⑧ 参见温海明：《本体论意义上的“情”何以是伦理的？》，《中山大学学报》2013 年第 2 期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

“思辨的心灵所最感兴趣的一切问题，几乎都是科学所不能回答的问题。”① 由此人们难免疑惑：同理心正义是否能经受住现代法律理性、客观性即科学性的考量？②

斯密认为，人生来就有同情心，就是“当我们看到或逼真地想到他人的不幸遭遇时所产生的感情……即使最大的恶棍，极其严重地违反社会法律的人，也不会全然丧失同情心”。③不仅如此，“引起我们同情的不仅是那些产生痛苦和悲伤的情形。无论当事人对对象产生的激情是什么，每一个留意的旁观者一想到他的处境，就会在心中产生类似的激情。”④ 这也就是说，除了设身处地的想象外，我们很难知道别人的感受、体验其处境，如何作出公正合理的判断？此即著名的旁观者理论。无数个公正旁观者的意见交集，便形成了“人同此心、心同此理”的道德和法律责任的基础，⑤ 理性或一致性、客观性便寓于其间。在休谟那里，同情心也被视为是人性中一条最显著的原则和一种最普遍的情感，是一种为每个人所具有的设身处地地体验他人感受的能力，它有助于形成以普遍性为基础的正义的道德感，⑥ 有一致性或客观性可循。虽然旁观者与当事人的感受很难达成完全一致，或者不会完全协调，但可以达到一定程度的和谐一致，这种和谐一致对于社会交往和道德判断而言已经足够。⑦

事实上，这也是胡塞尔以来现象学研究的问题。在现象学看来，移情是对陌生主体及其体验行为的经验，即在想象之中从陌生主体的立场当下化这个主体，理解其行为的主观意义和社会意义。⑧ 通过移情，经验“他人”并经验“自我”，形成“他我”，从而意向性地消解了近代形而上学的唯我论倾向；胡塞尔认为：“事物在这些体验中并不是像在一个套子里或是像在一个容器里，而是在这些体验中构成着自身”；⑨ 有效地保证了理解行为的客观进而确保对于“他人之心”进行恰如其分、如其所是的感知和确认。但经验又告诉人们，移情行为的客观并不能保证移情内容的

① 罗素：《西方哲学史》上卷，何兆武、李约瑟译，北京：商务印书馆，1963 年，“绪论”，第 11 页。

② 参见罗斯科·庞德：《机械法理学》，邓正来主编：《中国社会科学论丛：根据中国、走向世界》2011 年冬季卷，上海：复旦大学出版社，2011 年，第 125 页。

③ 亚当·斯密：《道德情操论》，蒋自强等译，北京：商务印书馆，1997 年，第 5 页。

④ 亚当·斯密：《道德情操论》，第 7 页。

⑤ D. D. Raphael, *The Impartial Spectator: Adam Smith's Moral Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 128.

⑥ 休谟：《道德原理探究》，王淑芹译，北京：中国社会科学出版社，1999 年，第 91—92 页。

⑦ 亚当·斯密：《道德情操论》，第 21—22 页。

⑧ 参见倪梁康：《胡塞尔的交互主体性现象学》，《中山大学学报》2014 年第 3 期。

⑨ 埃德蒙德·胡塞尔：《现象学的观念》，倪梁康译，上海：上海译文出版社，1986 年，第 16 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

客观，即实现类似情况类似移情结论的“同一感”，因为这中间横亘着鲜活、主观的个体，移情永远是通过“主体内”实现的，是一种“纯粹本己性”的体验。①

如何确保这种移情结论的“同一感”？对此，现象学进一步解析：借助移情，我们的身体和陌生身体之间会立即呈现出一种意向的交叠和意义传递，就会发现一种生动的相互的自身唤醒。也正因这种“相互的自身唤醒”和“意义转递”，我的自我立刻就会“转递”到陌生身体上，或者，陌生身体在移情中立刻就会被我的自我“统觉”和附体。如胡塞尔所说：我的“这个自我必须按照联想的整个意义给予过程而被必然地共现为处于在那里的样式中的现在共此在着的自我（‘好像我曾在那里一样’）”。② 如此被经验到的他人，就并非真正的他人，而是另一个自我即他我：是自我本身的映现，是我本身的相似者，是自我的一个镜像、一个重复，③ 由此移情者的移情结论就有了同一感特质。④

而以移情体验扩展开来的世界，即通过对被移情主体“重复客体化”和“当前化”的世界，就极可能是一个以“朝向事情本身”为目的、以“共同见证”的明见性为其原则的理性主义的客观世界。⑤ 这种理性主义胜过已不适合的旧理性主义，却又维护它最内在的目的。⑥ 也正是这一点，将移情想象与一般想象作了本质区别，通过移情看到的世界是一个实存的世界，而想象中看到的世界是一个不存在的世界。⑦ 即胡塞尔意义上交互主体构造的世界完全可能是同一个客观世界的核心理据——移情主体的开放性以及相应的各种不同参与视角的竞争性介入，进而消解“单个主体性始终具有相对于交互主体性的优先地位”可能带来的“唯我论”局限。⑧ 认知心理学的结论无疑是最具实证科学维度的结论。它通过诉诸生物学、生理学等研究手段后认为，尽管社会群体当中有着不同的社会结构，文化以及生理外表上的差别，但仍然存在着情绪方面的跨群体的共性，因而仍然有移情认同和跨文化一体感的客观性空间。⑨ 移情还有助于了解社会生活的个案事实，

① 艾迪特·施泰因：《论移情问题》，第 87 页。

② 埃德蒙德·胡塞尔：《笛卡尔式的沉思》，张廷国译，北京：中国城市出版社，2002 年，第 163 页。

③ 参见朱刚：《交互主体性与他人——论胡塞尔交互主体性现象学的意义与界限》，《哲学动态》2008 年第 4 期。

④ 参见郁欣：《施泰因的人格现象学》，《学术研究》2015 年第 4 期。

⑤ 参见朱刚：《交互主体性与他人——论胡塞尔交互主体性现象学的意义与界限》，《哲学动态》2008 年第 4 期。

⑥ 参见倪梁康：《现象学运动的基本意义——纪念现象学运动一百周年》，《中国社会科学》2000 年第 4 期。

⑦ 艾迪特·施泰因：《论移情问题》，第 70 页。

⑧ 倪梁康：《胡塞尔的交互主体性现象学》，《中山大学学报》2014 年第 3 期。

⑨ 霍夫曼：《移情与道德发展：关爱和公正的内涵》，第 326—327 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

实现更为丰富、完全的“理性”认知和反应。这是一种更为精致、具体的理性：充分的信息把握和信息评价，辄伴以一定的环境依托性和易变性。在此意义上，波斯纳大法官和博弈论大师宾默尔一再强调移情的认知意义：移情有助于防止“有效启示”，使讨论变得更为客观全面①或帮助人们做出“最优的反应”；② 而福利经济学甚至还有罗尔斯借助移情完成了理性选择/正义理论的建构。

上述探究表明，同理心正义尽管发端于心灵或情感体验，但仍然具有客观性、科学性的属性，并在实践中投射出逻辑属性，这种逻辑更多体现为意义的逻辑而非自然科学的逻辑：从相互性观念而非自然科学的角度加以理解，并最终演化为一种共同体心智意义上的客观性。③ 而就知识形态而言，同理心正义完全可以理解为波兰尼意义上默会知识的知识形态，它是“人类意识以不同的生活世界为基质进行运演的某种构造性潜能的实现”，④ 产生并依赖认知共同体的心智。⑤ 由此也决定了要把握这种客观性，需要各方尤其是法官具有较好的实践智慧。⑥ 正是在此意义上，美国法学家科尔曼和莱特把最大限度地富于同情和想象力作为理想的法官形象的非常重要的条件。⑦ 因为，“除非辅以对某种生活的移情和生活想象，否则（现代法律所特别强调）的计算思维的理论洞察将是相对短视和没有鉴别力的。”⑧

简言之，同理心正义作为一种情感，并非表面上看上去那样感性；它可以经受住法律科学性的检验，如同耶林笔下的法权感一样。⑨ 这重申了法律的基本品性：尽管强调对称性和逻辑性，但是法律规则启示的只是一种正义的情感。⑩

韦伯认为，法律、习俗、常规等社会规则是人们通过其行动创立出来的，在一定程度上体现着人们的主观意愿，因而难以用现代自然科学方法加以探究，相反，“理解”和“解释”为核心的方法才是应然之道；⑪ 利益法学的代表人物耶林对此的表述是：“法律首要的泉源以及原初泉源，就寓居在人类的胸中，而第二个、后来加

① 波斯纳：《法律理论的前沿》，第 252 页。

② 肯·宾默尔：《博弈论与社会契约（第 1 卷：公平博弈）》，第 39 页。

③ 参见 Brian Leiter，“Law and Objectivity，” in Jules Coleman and Scott Shapiro，eds.，*The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*，New York：Oxford University Press，2004，pp. 970-973.

④ 参见 W。麦肯纳：《客观性与交互文化的经验》，《南京大学学报》2001 年第 1 期。

⑤ 参见 Brian Leiter，“Law and Objectivity，” pp. 970-973.

⑥ 参见杜维明：《杜维明文集》第 5 卷，武汉：武汉大学出版社，2002 年，第 329—376 页。

⑦ 参见 Brian Leiter，“Law and Objectivity，” p. 982.

⑧ 玛莎·努斯鲍姆：《诗性正义：文学想象与公共生活》，第 103 页。

⑨ 冯·耶林：《法学是一门科学吗？》（上），《比较法研究》2008 年第 1 期。

⑩ 本杰明·N。卡多佐：《司法中的类推》，《外国法译评》1998 年第 1 期。

⑪ 郑戈：《法学是一门社会科学吗？——试论“法律科学”的属性及其研究方法》，《北大法律评论》第 1 卷，北京：法律出版社，1998 年，第 24—25 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进来的泉源，是生活的需求、匮乏以及实际的理智，这种悟性追寻着必要的目的与合适的手段。”① 霍姆斯的概括则成为经典：法律的生命从来不是逻辑而是经验。②

法学作为一种实践知识，无法用所谓的“科学”的“法律公理体系”的方法解决问题。③ 要判断法律的好坏，就必须审视运用法律达到了怎样的结果，而不是法律的内在结构有多精致；就必须考察它在多大程度上实现了法律的目的，而不是其逻辑过程是否优良或者法律规则从其赖以为基的教条中推演出来的过程是否严谨。④

因此，如果说法律有科学性，指的是经验的适当性。⑤ 与之相适应，法学的基本思维方式更多是一种设身处地的体验和感悟式思维方式，⑥ 关注的是其心理基础而非逻辑基础。⑦ 相应地，司法判决的过程也可以视为一个心理的过程。⑧ 正是在这个意义上，卢梭指出，法律中最重要的规则制度，并不是法典、条文等形式性的规定，而是人们心中所铭刻的法律规则。⑨

同理心正义契合法律科学性，意指应当有科学性也即经验的适当性，但不能唯自然科学论。肯定人的主体性及其经验的积极意义，可以使法律避免与常识和情理相悖，陷入伪科学的陷阱。

英国宪法学家卡罗尔·哈洛指出：“无论如何，为了增加法治的道德维度，就法治原理采取更柔和（而减少其刚性）的实质性解释的做法一直存在。”⑩ 按此逻辑，当代中国法律的发展应继续致力于对法律所蕴含的世道人心和天理人情的发掘，彰显道义性和意义性。当然，这需要法律深入社会日常生活，在实践中寻得其科学性：按照不同的意义关联，并依据经验事实建立科学的、普遍的行为类型。⑪

---

① 冯·耶林：《法学是一门科学吗？》（下），《比较法研究》2008年第2期。

② 小奥利弗·温德尔·霍姆斯：《普通法》，冉昊、姚中秋译，北京：中国政法大学出版社，2006年，第1页。

③ 舒国滢：《法学是一门什么样的学问？——从古罗马时期的Jurisprudentia谈起》，《清华法学》2013年第1期。

④ 罗斯科·庞德：《机械法理学》，邓正来主编：《中国社会科学论丛：根据中国、走向世界》2011年冬季卷，第125页。

⑤ Bas C. Van Fraassen, *Laws and Symmetry*, Oxford: Oxford University Press, 1989, p. 192.

⑥ 姚建宗：《中国语境中的法律实践概念》，《中国社会科学》2014年第6期。

⑦ 维特根斯坦：《逻辑哲学论》，郭英译，北京：商务印书馆，1985年，第93页。

⑧ 蔡墩铭：《审判心理学》，台北：水牛图书出版事业有限公司，1986年，“自序”，第1页。

⑨ 卢梭：《社会契约论》，何兆武译，北京：商务印书馆，1980年，第73页。

⑩ 卡罗尔·哈洛：《全球行政法：原则与价值的追问》，《清华法治论衡》2011年第1期。

⑪ 参见顾忠华：《导言：韦伯的社会行动理论》，马克斯·韦伯：《社会学的基本概念》，顾忠华译，桂林：广西师范大学出版社，2005年，第12页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

五、同理心正义的理论贡献及其限度

现代社会所践行的正义，在很大程度上是一种合法律性正义，也即是接受成文法规制的正义。所谓接受就是指："那些遵守这种实践的人认为这一规则是有约束力的，并且把这条规则看作是他们自己行为的一条理由或者正当理由，并且作为批评其他不遵守该规则的人们的一条理由。"① 由于规则本身可能荷载的价值意蕴不同，由此在正义的现代形象里，正义就有可能演化为各种面相——正如当代美国法学家伯科威茨所描述的：正义可能意味着公正；正义可能意味着效率；正义可能意味着合法性——但其核心却是一种公正而有效率的利益平衡机制，这种机制以生产合法的法律成果的方式而运行。② 很显然，这样一种合法律性的正义，对于从前现代迈向现代文明的国家而言，有着极其重要的意义，它确保了以法律的自治性和独立性为特征的"自治型法"及相应的现代法治的诞生。③

但是，我们也要清醒地认识到，这也可能带来了法律与正义的本真分离：法学最核心的问题意识被消解了——以正义为核心的法学变成了以合法律性为中心的学科。对此，伯科威茨认为：NBA 比赛里，终场前，落后一方出于利益需要选择技术犯规而中断计时，当然他们会为也愿为犯规埋单即受罚，但所有人都会认为这种行为是正当即正义的。因为在这里，正义仅是规则正义。然而，它却忽略了正义与生俱来的超验性：正当的行为应当要求人们超越规则去思考，比赛显然不仅仅是为了胜利——弘扬体育精神、促进友谊与合作也许是选项之一。④

这表明，正义不能等同于遵守法律；它还必须超越法律，以完成对某个"业已预定的伦理世界"或者"某一社会原初道德性"的超验性回应与荷载，否则作为"人类与正义理想之连接的理智感"⑤ 的法律也将面临深沉的危机。正基于此，伯科威茨一再提醒人们："我们正处于历史上一个独特的时代：法律与生活中的伦理活动之间一度神圣的联系被消解，正义正消亡，法律仅仅沦为政治和经济的工具，而这已经达到了一种直到最近都无法想象的程度。"⑥

---

① 罗纳德·德沃金：《认真对待权利》，信春鹰、吴玉章译，北京：中国大百科全书出版社，1998 年，第 38 页。

② 罗杰·伯科威茨：《科学的馈赠——现代法律是如何演变为实在法的》，田夫、徐丽丽译，北京：法律出版社，2011 年，"序言"，第 2 页。

③ 参见诺内特、塞尔兹尼克：《转变中的法律与社会：迈向回应型法》，张志铭译，北京：中国政法大学出版社，1994 年，第 53、63 页。

④ 罗杰·伯科威茨：《科学的馈赠——现代法律是如何演变为实在法的》，"序言"，第 2 页。

⑤ 罗杰·伯科威茨：《科学的馈赠——现代法律是如何演变为实在法的》，"序言"，第 1 页。

⑥ 罗杰·伯科威茨：《科学的馈赠——现代法律是如何演变为实在法的》，"序言"，第 7 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同理心正义的理论趣旨和目标追求是现代正义理论的超越性尝试：它以“人际”为分析单位，正义不仅是调节分配物质、利益的“分的正义”，也是一种韧性、细腻、周全的正义情感，还是一种互利共赢、亦此亦彼的人际/共在正义，其中，利益为其阿基米德支点，以移情为认知机制的承认合法型正义。① 中国语境中的同理性正义，可以从以下几方面理解：

第一，多样化、本土化正义。正义问题首先与司法裁量有关，同理心正义的重要性恰恰就在于它的组合或综合能力——能够从中国当下中国社会伦理和文化资源出发，建构多元、复杂、本土化的正义理论和实践；同时作为整合各方多元诉求的正当化/合法化机制，它也有效地将多样性寓于统一性之中。这样的正义，不仅不是对立法的普适正义的背叛，相反，恰恰是将之现实化的努力。②

第二，韧性、细腻、周全的正义情感。同理心正义内蕴了将心比心、换位思考的个案公正的作业和情感体验，这必然意味着其宽容、现实主义、周到和灵活性特点以及相伴而来的韧性、细腻的情感特质，并鲜明地区别于现代分配正义。后者聚焦于社会物品的分配及其意义，其核心就是使人各得其所。然而这种以物为核心的现代分配正义有着一种冷酷的基因——见物不见人，很容易造就社会底层正义阙如的分配格局和社会秩序。马克思就此指出：“分配关系本质上和这些生产关系是同一的，是生产关系的反面，所以二者共有同样的历史的暂时的性质”。③ 这表明，对正义问题的分析应超越分配正义的理路，将之嵌入充满移情、以需要为基础的公正元素的考量：关爱、相互依赖性和对他人利益的责任心……极端情形下甚至包括生命的保存这一更本体性的原则。

第三，互利共赢的“化解”的正义。正如前文所分析的，受当代中国文化资源的影响，当下中国其实很难接受没有道德内容的形式法治观。即使各方的诉求千差万别，也应提倡各方基于不言而喻的合作性、合意性以及互惠性和责任伦理而积极行为，通力协作，化消极为积极，进而实现互利共赢、“化解纠纷”的目的。④ 相应地，这样的正义无疑可谓为“化解正义”，一种建设性的互动正义。有学者认为，这种正义完全可以理解为同情和责任。⑤ 这里有着很强的正面的理想主义色彩，但却印证了中国司法独特的“阴”和“柔”一面，而不是现代形式正义的形象——“刚”

① 杜维明：《超越启蒙心态》，《国外社会科学》2001 年第 4 期。

② 许章润：《法律正义的中国语境——一种关于正义的程序主义法权进路（上）》，《战略与管理》2009 年第 5/6 期合编本。

③ 《资本论》第 3 卷，北京：人民出版社，2004 年，第 994 页。

④ 参见帕特里克·贝尔特：《二十世纪的社会理论》，瞿铁鹏译，上海：上海译文出版社，2002 年，第 136 页。

⑤ 参见何包钢：《三种全球正义观：地方正义观对全球正义理论的批评》，许纪霖主编：《全球正义与文明对话》，南京：江苏人民出版社，2004 年。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

且“烈”，冷漠而僵化。裁决也不再纠缠于非此即彼式的本质主义的二元对立，取而代之的是一种亦此亦彼的“妥协和忍、让的体系”。这里的妥协和忍让“不是披上伪装的有条件的投降，它的过程是积极的，因为促进了各方参与的兴致。它的过程也是合乎理性的”。①

第四，超越程序正义的承认合法性正义。这点与罗尔斯意义上的正义内在理论有异曲同工之妙。② 众所周知，现代法治乃程序之治，一切争取现代正义的主张均应在程序框架下展开，否则就真可能是“侈谈法治”、“侈谈现代正义”。

但在现代叙事中，一方面，这种程序正义往往相伴着程序本位的意味，即以人权或权利的名义，把原本分离的“正当性萎缩成合法性”。③ 事实上，程序本身只是技术框架，如果“被当成了目的本身而被追求，它会对程序的目的和法律的实体造成极大的损害”。④ 德沃金的道德成本理论对此一针见血：离开实体权利，程序保障基本上是一种政策而不是原则问题，因为任何有关特定程序保障的要求在这时都微弱得可以忽略不计。⑤

另一方面，程序不能等同于正义。对正义而言，程序只是必要条件。程序能够为人们反思正义提供一定的理论空间和理论进路，但依据何种标准、基础和原则来反思正义，程序却是无能为力的。相反，正义的实质内涵才是反思的基点。“正义最重要的内容即为确定正义实质内容的价值基准，但因以对人类之极度不信任为根据的相对主义，不得不将其抛弃，转向可经验、检验的程序正义领域。”⑥ 也就是说，程序正义只是正义的一种尺度，实质正义才是正义的核心组成。同理心正义正是这样的尝试：在程序语境下，发现和找出反思标准的伦理源头或者说“具有超越的客观性或历史正当性的伦理体系的支撑”，通过历史和现实反馈、普遍参与和公共讨论，以获得相应的社会和文化意义上的合法性、正当性以及“作为公共性的客观性”。⑦

不可否认，同理心正义在收获其可能的理论贡献的同时也有其理论的局限性。

首先，同理心正义主要是一种实践层面的正义理论，也即正义及其产生的效力性问题，主要来自于经验的洞见和归纳而不是来自于规则的演绎适用，通常表现为

① 科恩：《论民主》，聂崇信、朱秀贤译，北京：商务印书馆，1988年，第184页。

② 参见刘莘：《现代性政治哲学的基础共识：从施特劳斯到罗尔斯》，《西南民族大学学报》2014年第6期。

③ 参见周濂：《正当性与合法性之辩》，《读书》2014年第5期。

④ 罗斯科·庞德：《机械法理学》，邓正来主编：《中国社会科学论丛：根据中国、走向世界》2011年冬季卷。

⑤ Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*, Boston: Harvard University Press, 1985, pp. 110-114.

⑥ 德国法学家库尔特·泽尔曼语，参见李在龙：《正义论之中国哲学的根基》，《浙江社会科学》2014年第9期。

⑦ 参见 Brian Leiter, “Law and Objectivity,” p. 986.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

常识正义。然而常识往往具有零散性、狭隘性、极端性和保守性等特征。① 这种正义也就自然缺乏应有的完整性、系统性、前瞻性，甚至在极端情形下，可能异化为画地为牢的正义，既缺乏深厚的历史感，也缺乏真正的现实感，有一种认识论上的相对主义之虞，故而仍然不是至善的正义。②

其次，由于移情可能存在的局限，包括移情过度唤醒以及容易受两种偏好的破坏，包括熟习偏见和此时此地偏见，③ 这决定了同理心正义难免有偏见之嫌，进而成为公平裁断的障碍，这完全是有可能的。也正因有这种可能，所以波斯纳再三强调，裁决过程一定要防止“有效启示”，因为“有效启示容易导致目光短浅的司法判决”，并引入了一个概念“司法气质”，即移情上的超然作为防范措施。④ 尽管如此，正如霍夫曼所指出的，这种移情偏见也是正常的，可以接受的；同时通过加强移情力量的建设性作用以及道德社会化建设，促进个体对社会中他人的移情以及移情同关爱——公正法则之间联系的发展，⑤ 移情偏见完全是可以得到降低、悬置甚至克服的，当然，这也非一蹴而就的。

最后，同理心正义可能会鼓励人们以一种特别的方式看待中国的形式法治及相应的司法哲学：正义的首要美德不在于根据规则裁决案件，而是要涉及包括财富及权力分配在内的社会正义问题。裁判的过程不仅是一个法律推理的合法性证成过程，而且也是一个个案情理正当性证成的过程。由此正义只能是“比较性的”，只能用来识别和清除真实世界的“明显不正义”。这显然需要一批具备良好职业素养的法律人和社会大众的宽容作核心支撑，并无疑也是我们继续努力完善的基本方向。

同理心正义理论的建立以现实生活为基础，而不只是停留在抽象的制度和规则上，强调公共理性和反思，而不是寻找一成不变的公理性答案，强调情感的认知意义，情感和理性的双重加工理论，⑥“召唤逻辑的法则，维护常识的权利。”⑦

〔责任编辑：赵　磊〕

① 参见孙正聿：《解放思想与变革世界观》，《中国社会科学》2008 年第 6 期。

② 参见菲利普·佩迪特：《人同此心：论心理、社会与政治》，“序言”，第 6 页。

③ Martin L. Hoffman，“Empathy，Justice，and the Law，” pp. 250-251；霍夫曼：《移情与道德发展：关爱和公正的内涵》，第 223—244 页。

④ 波斯纳：《法律理论的前沿》，第 253 页。

⑤ 霍夫曼：《移情与道德发展：关爱和公正的内涵》，第 331—332 页。

⑥ Anna Ronkainen，“Dual-Process Cognition and Legal Reasoning，” 2011. https：//papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm？abstract _id＝2004336，2016 年 11 月 10 日。

⑦ 迪昂：《物理学理论的目的和结构》，李醒民译，北京：华夏出版社，1999 年，第 117—118 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

trap" and thus facilitating rapid and sustainable economic growth.

(5) The Topic of Social Policy in the New Normal Economy

Wang Sibin and Guan Xinping • 80 •

With the "new normal" of the Chinese economy' s shift from rapid growth to rapid but stable development comes the opportunity for redressing previous imbalances in social and economic growth. A number of complex, changing and recurrent economic and social problems indicate that Chinese social policy will undergo quite a major adjustment. Against this background, discussing the choice of strategic policy directions and related issues will be profoundly significant for reform and innovation. Wang Sibin, Professor of Sociology at Peking University and Research Fellow at the China Social Work Research Center, points out that, in the new normal of economic development, we need an active social policy support, which is the combination of active social policy and policy implementation. The underpinnings of such a social policy should develop from being purist, narrow and remedial to offering recipients assistance and help that are scientific, humanist, integrated and developmental. Whether from the perspective of the needs of policy recipients or that of resource mobilization, social policy support needs to be holistic, take an integrated approach to disadvantaged groups, and be designed and implemented as a whole. The construction of active social policy support is not only practically significant for resolving the social problems of today' s economic transformation, but also an important foundation for the construction of China' s social policy system. Professor Guan Xinping of the Institute of Social Construction and Management and Department of Social Work and Social Policy in Nankai University, holds that although Chinese social welfare has improved greatly over the past decade, it is still rather low compared with today' s requirements for the building of a moderately prosperous society in all respects. In China' s new economic and social situation, social policies are not only significant for ensuring and improving people' s livelihood and maintaining social justice, but can also play a greater role in facilitating economic development. To fulfill the new concept of development and requirements for justice, improved livelihood and shared development put forward by the Party Central Committee and to better facilitate transitional economic development, China should continue to raise the level of social policy goals and general welfare and should aim for a win-win situation in which social policy supports both welfare and development.

(6) Judicial Impartiality and Empathetic Justice *Du Yanlin* • 102 •

The increasingly diversity of society' s demands means that the impartial operation of justice is faced with a rather complex predicament. Empathetic justice can maximize the justice of verdicts in individual cases and can also handle the

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

universality of the pursuit of justice appropriately; its demonstration of prosocial public reason offers a way out of this dilemma. Not only is empathetic justice a diverse and dynamic form of justice; it also provides a relatively satisfactory interpretation of the equivalence and convertibility of justice. As well as showing interaction and sensitive resonance of intersubjetivity, it is a vehicle for rich virtues of justice. Although empathetic justice originates in the mind or in emotional experience, it can withstand the scientific legal tests. At the same time, it remains imperfect, and certain defects in its operational mechanism may produce some adverse factors.

(7) The Application of Judicial Methods in Adjudication: Supremacy of Legal Rules, Principle-based Judgements and Assessment of Consequences *Ren Qiang* · 121 ·

Together with principle-based judgements and assessment of consequences, the supremacy of legal rules provides effective analytical tools and methods of adjudication that enable judges to deal with different types of cases. "Supremacy of legal rules" means that judges must abide by the meaning of the letter of the law. As the general rule governing the operation of modern justice, this is the fundamental requirement imposed on judges in a society with rule of law. A judgment that deviates from legal rules or the letter of the law is simply a special case or an exception. However, when legal rules are unavailable, or compliance with the literal meaning of a legal rule mean that no judgment or only an unfair or absurd judgment is possible, or the conflict between different rules leads to impossible choices, courts need to invoke legal, moral or political principles that contain value judgments. In tricky cases that are not covered by legal rules and are not related or only remotely related to the three types of principle mentioned above, where there is a conflict between legal rules, principles or interests, or where common sense is violated, possible consequences must be weighed before any judgment is made. The three types of judicial method can be used separately or together, but applying them together can make the ruling more persuasive without damaging the independence of judicial method. Differences in judicial method constitute the basis of judgments.

(8) Symmetry and Formal Changes in the New Poetry of the May Fourth Movement *Wang Zelong and Gao Jian* · 143 ·

As an important formal feature of poetic structure, symmetry can be divided into two types in the concrete practice of poetic composition: the "symmetry" that pursues exact consistency, and the "symmetry" that mixes "consistency" with "inconsistency." In the New Poetry reform of the May Fourth period, poetry's symmetric forms underwent a change to modernity, taking the first steps toward completing its reform from the exact consistency of the old style to free and diverse modern poetic forms. The symmetry in the new poems was mainly embodied in

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net